

1003247-52.2022.8.26.0114

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Magistrado: PATRICIA PERSICANO PIRES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 16ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... do CP): 5 (cinco) anos associação para o tráfico (art. 35, c.c. art. 40, II, da Lei nº 11.343/06): 5 (cinco) anos e 3 (três) meses pena finalizada (na forma do art. 79, CPM): 10 (dez) anos e 3 (três) meses, regime inicialmente fechado (<https://ww2.tjmsp.jus.br/ExibirPDF.aspx?Id=6315-2020>).

Embargos de declaração não acolhidos. Consta do extrato processual a interposição de recurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

16ª Vara da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1003247-52.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003247-52.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Impetrante:

Márcio Rebouças dos Santos

Impetrado:

Cel PM Chefe do Departamento Pessoal da Polícia Militar

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES

Vistos.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Márcio Rebouças dos Santos contra ato tido por coator praticado pelo Cel PM Chefe do Departamento Pessoal da Polícia Militar. Alegou, em resumo, ser policial militar, matriculado nas fileiras da Corporação em 16/09/1991; até 27 de agosto de 2021, o impetrante encontrava-se com 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de serviços prestados; sucede que a Administração não considerou como tempo de serviço o período em que o impetrante se encontrava detido cautelarmente no Presídio Militar, correspondendo a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses, 1 (uma) semana e 4 (quatro) dias, em face da agregação (14 de agosto de 2018 a 25 fevereiro de 2021); sustenta que, fosse considerado o período, bem ainda a data da propositura da ação, o impetrante teria direito à promoção e transferência para a reserva Remunerada; formulou pedido nesse sentido, mas foi indeferido ao argumento de que o impetrante não preenche os requisitos legais dispostos nos artigos 24-A ao 24-G do Decreto Lei 677/69, dado o período em que permaneceu preso por conveniência da Justiça Militar; argumenta que tal decisão é ilegal, pois mesmo preso, não houve interrupção dos lançamentos do soldo militar, nem suspensão dos descontos previdenciários. Diante disso, pretende

a concessão de ordem para que a autoridade impetrada promova o impetrante ao cargo imediato e o transfira para a reserva (aposentadoria definitiva), sendo emitida nova certidão de tempo dos serviços prestados pelo servidor estadual, incluindo o período anteriormente suprimido, 14 de agosto de 2018 até 25 de fevereiro de 2021.

A liminar foi indeferida (fl. 74).

A Fazenda do Estado de São Paulo requereu sua admissão no feito (fl. 79).

A r. Decisão de fl. 93 determinou a redistribuição dos autos à Capital.

Notificada, a autoridade impetrada apresentou informações (fls. 108/117). Sustentou ser parte ilegítima. Quanto ao mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a contagem de tempo de serviço na Polícia Militar se faz na forma do artigo 51 do Decreto-lei nº 260/70, alterado pela Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, ausente previsão de que o tempo em que o policial militar se encontrava afastado de suas funções possa ser incluído na contagem; uma vez que o impetrante estava agregado, permaneceu inativo temporariamente, conforme artigo 4º do Decreto-lei nº 260/70, de modo que o tempo de agregação não pode ser computado para fins de tempo de serviço; ao impetrante não é aplicável o disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 260/70, com redação dada pela Lei Complementar nº 1.305, de 20 de setembro de 2017 uma vez que não há prova de que tenha havido o arquivamento do inquérito policial ou que tenha sido absolvido por negativa de autoria ou inexistência do fato; não há respaldo à pretensão na Lei Estadual nº 10.261/68; por isso, ausente tempo de 30 anos de serviço, concluiu com o pedido de denegação da segurança.

Intimado, o Ministério Público afirmou inexistir interesse público a justificar sua intervenção no mérito do feito (fls. 88/91 e 121/124).

É o relatório.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

Admito o ingresso da Fazenda Pública do Estado na lide como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 e ss. do Código de Processo Civil e dos arts. 7º, II, e 24 da Lei nº 12.016/09. Anote-se.

Afasto a alegada ilegitimidade passiva, na medida que a autoridade integra a Corporação, prestou informações e manifestou-se quanto ao mérito, razão por que aplico a teoria da encampação.

Passo ao exame do mérito.

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).

No caso em exame, o impetrante requer a concessão da segurança para reconhecer o direito à inclusão do tempo que ficou preso cautelarmente, e afastado do exercício do cargo, como tempo de serviço necessário à promoção e transferência à reserva.

Conforme descrito na inicial, o impetrante permaneceu preso preventivamente entre

14 de agosto de 2018 e 25 fevereiro de 2021.

Em consulta aos autos do processo mencionado na fl. 26, verifiquei que o impetrante foi condenado em 1º grau, mantida a condenação em 2º grau, às seguintes penas: concussão (art. 305, do CPM, c.c. art. 71, do CP): 5 (cinco) anos associação para o tráfico (art. 35, c.c. art. 40, II, da Lei nº 11.343/06): 5 (cinco) anos e 3 (três) meses pena finalizada (na forma do art. 79, CPM): 10 (dez) anos e 3 (três) meses, regime inicialmente fechado (<https://ww2.tjmsp.jus.br/ExibirPDF.aspx?Id=6315-2020>).

Embargos de declaração não acolhidos. Consta do extrato processual a interposição de recurso especial e extraordinário pelo impetrante.

Como é cediço, a prisão do servidor implica no afastamento do exercício do cargo, nos termos do disposto no artigo 70, da Lei nº 10.261/1968, in verbis:

Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado.

§ 1º - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão.

§ 2º - Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público.

Da leitura da norma acima transcrita, é possível extrair que o servidor preso cautelarmente é considerado afastado do exercício do cargo, e, portanto, o desconto do período de prisão cautelar do cômputo de tempo de serviço do impetrante decorreu da aplicação da hipótese legal ao caso concreto, tendo a Administração Pública agido no estrito cumprimento do princípio da legalidade.

Cumprе salientar que, quanto aos benefícios de ordem de carreira, apesar de continuar contribuindo para a previdência durante sua prisão cautelar, ante os descontos feitos em seus vencimentos, não é possível considerar o período de seu cárcere como tempo de efetivo serviço prestado.

Estando o impetrante preso, não há como realizar seus afazeres funcionais ou prestar os serviços relativos às suas atividades policiais, encontrando-se seguramente afastado de suas funções.

Não há previsão legal para incluir o afastamento em razão de prisão processual.

Nessa linha de entendimento, não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO POLICIAL MILITAR PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO EM QUE ESTEVE AGREGADO IMPOSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I, DECRETO-LEI Nº 260/70 SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO4 . APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de contagem do tempo em que esteve preso para todos os fins legais, com pagamento dos salários atrasados Decadência. Inocorrência. Coisa julgada no tocante ao pedido de recebimento dos salários atrasados. Impossibilidade de contagem do tempo em que o impetrante permaneceu na condição de agregado para fins de adicional por tempo de serviço, férias, licença-prêmio e inatividade. Arts. 4º, 5º, VIII, 7º, 8º e 9º, Decreto-Lei n. 260/70. Art. 129 da Constituição Estadual que exige o efetivo exercício do cargo para fins de adicional por tempo de serviço Art. 9º, II, Lei n. 1.020/07 que determina expressamente a interrupção da contagem da licença-prêmio no caso de agregação Sentença mantida Recurso improvido." (TJSP; Apelação 1006784-55.2016.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 12/09/2017).

Portanto, sem a previsão legal para considerar o período de afastamento decorrente de prisão como hipótese de cômputo de tempo de serviço, não há a possibilidade de acolher o pedido do impetrante no tocante à inclusão do tempo que ficou preso indevidamente como tempo de serviço sem desrespeitar o princípio da legalidade.

Dessa forma, inviável a concessão da contagem de tempo do servidor afastado para fins de promoção e transferência para a reserva porque ausente o impetrante de sua efetiva atividade.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas e despesas na forma da Lei, observada eventual gratuidade.

Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do art. 25 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.

Dispensado o reexame necessário. Decorrido o prazo para recursos voluntários, arquivem-se.

Publique-se e intímem-se.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

PATRICIA PERSICANO PIRES  
- Juiz(a) de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA